



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/210/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובעת:
תבל שירותי סיעוד לעובדים זרים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יגאל מדר
מרחוב בן יהודה 12 ירושלים

- נ ג ד -

הנתבעת:
מרכז הפעמון – חברה לניהול ואחזקה 92 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד טל ליפר
מרחוב יפו 33 ירושלים

ה ח ל ט ה

מבוא

1. במסגרת ההליך עותרת התובעת לחיוב הנתבעת לאפשר עיון במסמכיה בהתאם להוראות סעיף 16 לתקנון המצוי. התובעת טוענת כי הנתבעת הינה חברת ניהול אשר משמשת כמתחזק של הבית ובהתאם חובתה על פי הוראת התקנון האמורה.
2. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי במסגרת הליך אחר בין הצדדים, במסגרתו תבעה היא את התובעת דנן לתשלום מיסי נציגות, נפסק, בקביעה חלוטה של המפקחת ענתבי-שרון, כי הנתבעת דנן איננה מתחזק הבית ובהתאם הועבר הדיון בתובענה מלשכת המפקח לבית משפט השלום.
3. בהתאם להחלטתי הוגש כתב תשובה במסגרתו שבה וטענה התובעת כי הנתבעת הינה מתחזק הבית ובהתאם זכותה לעיין במסמכיה. הנתבעת דנן לא כפרה בסמכות המפקח בהליך הקודם שבין הצדדים או בטענת התובעת בהליך זה כי הינה בגדר מתחזק. קביעת המפקחת בהליך הקודם נעשתה לעניינו בלבד ובמסגרת ההליך ההוא וככל שתוכל הנתבעת להוכיח את מעמדה כמתחזק הרי שגם היא לא תהיה מושתקת בקביעה האמורה שניתנה אך בשל מחדליה להוכיח את תביעתה. בנסיבות דנן לא חל השתק שיפוטי וגם לא מעשה בי-דין כאשר ממילא ההליך הקודם (שהועבר לשלום) טרם הסתיים.
4. בתשובה לכתב התשובה (בהתאם להחלטתי) שבה ומבהירה הנתבעת כי מדובר בטענות סותרות בהליכים משפטיים שונים – טענת התובעת בהליך הקודם שבין הצדדים, שהתקבלה, לפיה הנתבעת דנן איננה בגדר מתחזק, משתיקה אותה מלטעון אחרת בהליך דנן. כל מטרת ההליך לעקוף החלטות בית משפט השלום בתובענה הכספית שבין הצדדים.

דיון

5. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות אני מוצא לנכון לקבל את טענת הנתבעת ולהורות על דחיית התביעה על הסף, בין מחמת מעשה בי-דין ובין מחמת השתק שיפוטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/210/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מעשה בית דין

6. בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים. הראש האחד עניינו בהשתק עילה ... הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל השתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסינותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ((ההדגשה שלי, א.ס.).

7. ישומן של ההלכות האמורות מוביל למסקנה כי, במקרה דנן, מתקיים מעשה בית דין מסוג השתק פלוגתה, אשר משתיק את בעלי הדין מלהתדיין שוב לגבי שאלת מעמדה המשפטי של הנתבעת בבית.

8. במסגרת ההליך בתיק 01/230/13 בפני כב' המפקחת ענתבי שרון נדונה לגופה השאלה בדבר מעמדה של הנתבעת דנן (התובעת באותו הליך) כ"מתחזק" בהתאם להוראות חוק המקרקעין. במסגרת אותו הליך טענה התובעת דנן (הנתבעת שם) כי הנתבעת דנן איננה בגדר "מתחזק".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/210/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לאחר דיון לגופם של דברים, בהחלטה פוזיטיבית מנומקת וארוכה מיום 18.03.14 (להלן: **ההחלטה**), מצאה המפקחת כי הנתבעת דנן איננה בגדר "מתחזק" מכוח חוק המקרקעין ובהתאם, בהעדר עילה בידה מכח אותו חוק, הועבר הדיון בתובענה לבית משפט השלום מכוח עילות אחרות המצויות בסמכותו.

וידגש, במסגרת ההחלטה קבעה המפקחת כי לא התקבלה החלטה כנדרש על מינוי הנתבעת כמתחזק וגם לא הוכחה הסכמה מכח הסכמי הניהול (ר' סעיפים 30-34 להחלטה).

9. החלטת המפקחת ניתנה כאמור ביום 18.03.14 ומאז הפכה חלוטה – ראשית, מאחר ולא הוגש ערעור בזכות על החלטה זו, בין מכח הוראות סעיף 77 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 ותקנה 83 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב - 2011 ובין מכח היות ה"החלטה" בגדר "פסק דין" בתובענה אשר נדונה בפני המפקחת מאחר והיה בה לסיים באופן סופי ומוחלט את ההליך בפניה. שנית, טענת התובעת דנן התקבלה באותה החלטה כך שממילא אין בידה, ולא היתה בידה, זכות לערער על אותה החלטה שהפכה חלוטה מבחינתה.

10. משהוכרעה הפלוגתא ביחס למעמדה של הנתבעת בבית ונקבע באופן חלוט כי היא איננה בגדר מתחזק, הרי שקביעה זו מחייבת את הצדדים להליך גם בהליכים אחרים המתנהלים בניהם בבחינת מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא – לא התובעת ולא הנתבעת זכאיות לפתוח לדיון מחדש את שאלת מעמדה של הנתבעת בהעדר שינוי נסיבות מהותי, עובדתי או משפטי, אשר יש בו לשנות ההכרעה.

11. וידגש, עיון בהחלטת המפקחת כאמור מלמד כי הפלוגתא בדבר שאלת מעמדה של הנתבעת דנן, שאלה מהותית וחיונית במסגרת ההליך הקודם, הוכרעה באופן פוזיטיבי ומפורש על כל רכיביה העובדתיים והמשפטיים, לאחר שניתנה לצדדים זכות טיעון מלאה ומשמעותית, לרבות, להצגת ראיות ואסמכתאות נדרשות להכרעה (ר' סעיפים 5 ו-19-25 להחלטה).

12. על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר במסגרת ההליך הקודם היתה זו התובעת דנן שטענה כי הנתבעת איננה בגדר "מתחזק" בבית – עמדתה של התובעת בנוגע לפלוגתא היא זו שהתקבלה! קבלת עמדת התובעת בהליך דנן משמעה עיקור מתוכן מוחלט של הכלל בדבר השתק פלוגתא, ודאי בנוגע לצד אשר זכה בדין בנוגע לפלוגתא הנדונה בהליך המוקדם.

13. עוד וידגש, התובעת איננה מבססת את תביעתה דנן על עובדות חדשות או טענות משפטיות שונות מאלו אשר נדונו במסגרת ההליך הקודם. התובעת לא מעלה בכתבי הטענות מטעמה כל טענה כי מעמדה של הנתבעת השתנה מאז החלטת המפקחת כאמור, בין בהיבט העובדתי ובין בהיבט המשפטי, לרבות לא בכתב תשובה ארוך ומפורט שהוגש מטעמה - אם, כטענת התובעת, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח במסגרת ההליך הקודם כי הינה מתחזק (טענה אשר מחייבת תימוכין עובדתי), ברי כי גם כיום אין בידה של התובעת להוכיח את האמור לאור עמדתה במסגרת ההליך הקודם, לרבות בנוגע להסכמי הניהול והחלטת המינוי (ר' סעיפים 4 ו-14 להחלטה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/210/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

14. די בכך כדי להביא לדחיית התביעה על הסף שעה שמכתב התביעה עולה במפורש כי עילתה בסעיף 16 לתקנון המצוי בלבד ואשר יש בו לחייב את הנתבעת רק אם וככל שהינה מתחזק בבית כהגדרתו בחוק.

משעה שהתובעת היא זו אשר טענה, משפטית ועובדתית, והביאה לכך שיוכרע באופן סופי כי הנתבעת איננה מתחזק בבית, הרי שאין בידה כל סעד מכח הוראות חוק המקרקעין כנגד הנתבעת.

15. בנסיבות דנן ישנו מקום לדחות את התביעה על הסף גם מחמת קיומו של "השתק שיפוטי".

"השתק שיפוטי"

16. ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ (פורסם בנבו) סוקר כבוד השופט גרוניס את עיקרי הדוקטרינה:

8. ההשתק השיפוטי הוגדר במילים אלה על ידי השופטת ד' דורנר: **"בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושקת מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר (שבעניינו לא נוצר מעשה-בית-דין) ולטעון טענה הפוכה"** (ע"א 513/89 Interlego נ' Exin-Lines, פ"ד מח(4) 133 (להלן - פרשת אינטרלגו) 194). בעוד שבפרשת אינטרלגו דובר בעיקר על השתק שיפוטי, מוצאים אנו שימוש בדוקטרינות או במונחים אחרים לגבי אותו כלל. כך למשל, בעניין אחד דובר על תקנת הציבור (ע"א 1393/02 קזצ'קוב הבל נ' קזצ'קוב, פ"ד מח(4) 353, 358), בעניין אחר על בחירה בין חלופות (election) (ע"א 27/80 ישראל ארגמן חברה לבנין בע"מ נ' ברנדפלד, פ"ד לו(1) 393, 400 ; וכן ראו פרשת אינטרלגו, עמ' 194) ובמקרים נוספים על שימוש לרעה בהליכי משפט (ע"א 4361/90 ג'ול נ' אל ג'ול, פ"ד מט(5) 656, 659 ; ע"א 158/83 פינקל נ' נוימן, פ"ד לח(1) 17, 27). ניתן לראות בכל אחד ואחד מאלה ענף הצומח מתוך עץ תום הלב (פרשת אינטרלגו, עמ' 199 ; ע"א 658/80 אליאב נ' הסנה, פ"ד לו(3) 543, 552).

9. הטענה בדבר השתק שיפוטי יכולה להתעורר מקום בו אחד מבעלי הדין מעלה טענות עובדתיות או משפטיות סותרות באותו הליך עצמו או בשני הליכים שונים (ניתן לראות באיסור על העלאת טענות עובדתיות חלופיות כנגד אותו בעל דין בכתב טענות אחד משום דוגמה של השתק שיפוטי; האיסור קבוע בתקנה 72(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). התכלית שמאחורי ההשתק השיפוטי היא למנוע פגיעה בטוהר ההליך השיפוטי ובאמון הציבור במערכת המשפט וכן להניא מפני ניצולם לרעה של בתי המשפט (פרשת אינטרלגו, עמ' 200 ; R. G. Boyers "Precluding Inconsistent Statements: The Doctrine of Judicial Estoppel", 80 Nw. U.L. Rev. 1244 (1986) (להלן - Boyers), עמ' 1250-1251). בעוד שתורת ההשתק מכוח מצג מתמקדת בצדדים ובמערכת היחסים ביניהם, הרי הדגש בהשתק השיפוטי הינו על היחס בין בעל הדין לבין בית המשפט. מכך אף נובע שתחולתו של ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת למצב דברים בו מדובר באותם מתדיינים בהליך הראשון ובהליך המאוחר (פרשת אינטרלגו, עמ' 598; 196 Edwards v. Atena Life Insurance Company, 690 F.2d 595 (1982) (להלן - פרשת אדוארדס)), ואף אין דרישה שהצד האחר שינה את מצבו לרעה (Spencer Bower & Turner "The Law Relating to Estoppel by Representation" 3rd ed. (1977)). זאת ועוד, טענה בדבר השתק שיפוטי יכולה לעלות בלא קשר לנושא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/210/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

המשפטי המהותי העומד על הפרק.

10. בפסיקתנו נקבע, בעקבות פסיקה אמריקאית, כי אחד התנאים לקיומו של השתק שיפוטי הינו הצלחה בהליך הקודם (ראו לדוגמה, רע"א 6753/96 מ.מ.ח.ת. בע"מ נ' פרידמן, פ"ד נ(5) 418, 422). כלומר, תנאי הוא שבעל הדין כלפיו נטען ההשתק השיפוטי זכה בהליך הראשון על סמך טענה שאת היפוכה הוא טוען בהליך השני (הכלל מכונה באנגלית *Prior success rule*, ובלשונו "כלל ההצלחה הקודמת"). הכלל האמור נובע מן החשש שתקבלנה החלטות סותרות על ידי שני טריבונלים שונים (ראו *Boyers*, עמ' 1253). לפיכך, אם בית המשפט הראשון דחה את טענתו של בעל הדין, אין מניעה, לאור הכלל האמור, שהוא יעלה טענה סותרת בהליך המאוחר. כמובן, שכאשר מדובר בעדות הסותרת עדות קודמת, תפגע הסתירה במהימנותו של העד בהליך השני, אף אם לא נקבע מימצא על סמך עדותו בהליך הראשון (אם נקבע מימצא, ייתכן שיחול השתק אחר, הוא השתק פלוגתא) (ההדגשות שלי, א.ס.).

17. בחינת הכלל האמור על נסיבות המקרה דנן מובילה למסקנה בדבר תחולתו כאמור -

במסגרת ההליך הקודם טענה התובעת כי הנתבעת דנן איננה בגדר מתחזק בבית - ויודגש, מדובר בטענה הכוללת היבטים עובדתיים ומשפטיים כאחד.

במסגרת ההליך הקודם התקבלה טענתה של התובעת בשני ההיבטים האמורים.

עתה במסגרת הליך זה טוענת היא טענה הפוכה בשני ההיבטים - העובדתי והמשפטי, ומנסה להיבנות מטענות הנתבעת בהליך הקודם (שנדחו), על כך שהיא כן בבחינת "מתחזק" בבית, כל זאת ללא שהשתנו הנסיבות העובדתיות כלל!

18. בדיוק לשם הנסיבות האמורות נועדה טענת ההשתק השיפוטי וכפי שצוטטה לעיל, במיוחד כאשר הטענה הוכרעה לטובת התובעת כאמור!

19. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי בניגוד לטענת התובעת, הרי שההכרעה בנוגע למעמדה של הנתבעת כמתחזקת במסגרת ההליך הקודם הינה הכרעה סופית וחלוטה, המהווה פסק דין בהליך שניתן לטובת התובעת דנן (הנתבעת שם).

20. ויודגש, למעשה בתביעתה מבקשת התובעת כי נכיר בנתבעת כמתחזק לעניין החובות המוטלים על גוף שכזה מכח הוראות החוק (למשל, חובות הגילוי אליהן מתייחס ההליך דנן) ובהתאם לזכות אותה בסעדים בגין חיובים אלו. מאידך, מבקשת היא שלא נכיר בנתבעת כמתחזקת לעניין הזכויות להן היתה זכאית, לו היתה מוכרת כמתחזקת על פי החוק (למשל, תשלום מיסי נציגות או דמי ניהול) ובהתאם גם לא נחייב את התובעת במילוי חובותיה החוקיים כלפיה (כפי שאכן נקבע במסגרת ההליך הקודם).

עצם העלאת הטענה בצורתה האמורה, ודבקות התובעת בטענות הפוכות וסותרות, בכל מקרה נדון על פי צרכיה, כשכל מטרת הטענות להשיא את זכויותיה ללא חיובים בצידם, מגלמת מידה משמעותית של חוסר תום לב דיוני ומהותי, ודאי לאור ההכרעה המהותית במסגרת ההליך הקודם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/210/2016

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

21. די גם באמור להצדיק סילוק התביעה על הסף וזאת עוד בטרם נדרש לטענות נוספות של הנתבעת, שיש טעם גם בעניינן, לפיהן מדובר בהליך שמטרתו לעקוף החלטות שניתנו בבית משפט השלום במסגרת ההליך המקביל שמתנהל בין הצדדים לאור ההחלטה.

סיכום

22. לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון להורות על דחיית התביעה על הסף.

23. ברי כי בידי התובעת שמורות זכויותיה מכח מערכת היחסים החוזית שבין הצדדים.

אולם, אין בידה לחייב את הנתבעת מכוח הוראות חוק המקרקעין – שעה שהוכרע באופן פוזיטיבי ומחייב כי הנתבעת איננה בגדר מתחזק, הרי שכשם שאין לה זכויות מכח התקנון גם אין לה כל חובות מכוחו!

24. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

25. בנסיבות דנן אני מוצא לנכון לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעת בהליך בסך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

26. בפסיקת גובה החזר ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהוגשו כתבי טענות מטעם הצדדים וכי התובענה נדחתה על הסף, עוד בטרם דיון בה.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום כ"א תמוז תשע"ו, 27 יולי 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים